Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Anastácio

1ª Vara

Autos nº: 0800017-70.2019.8.12.0052 – Procedimento Comum Cível
Autor(es): Rosemeire Marina Neves Costa
Réu (s) : Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Hospital Cassems - Unidade Aquidauana

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Cuida-se ação indenizatória por danos morais e estéticos ajuizada por **Rosemeire Marina Neves Costa** contra **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Hospital Cassems - Unidade Aquidauana**, ambos qualificados.

Aduziu a parte autora, em síntese, em 11/08/2018 sofreu acidente automobilístico que lhe causou escoriações pelo corpo, fratura em uma das vértebras do ombro e lesão na orelha direita. Disse que no hospital foram prestados primeiros socorros, sendo submetida a exames de tomografia e raio-X. Verbalizou que foi atendida por equipe de plantão e foi constatado que deveria ser transferida para Santa Casa de Campo Grande para ser

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

submetida a cirurgia reparadora da orelha direita.

Alegou que a vaga na Santa Casa de Campo Grande foi disponibilizada às 23:30h do dia fatídico. Asseverou que o médico responsável por seu caso informou a solicitação da ambulância para remoção e que a previsão de chegada era 02:30h do dia 12/08/2018, todavia, às 03:00h não havia chego. Noticiou que ao buscar informações acerca do trânsito da ambulância foi dito que não teria saído de Campo Grande-MS. Narrou que chegou a Campo Grande somente às 07:00h do dia 12/08/2018, por meio particular. Relatou que a cirurgia plástica não pode ser realizada em razaão da demora na transferência entre os hospitais de Aquidauana e Campo Grande.

Sustentou que sofreu dano na esfera moral e estética por negligência da parte requerida e de preposto perdeu mais de 80% da orelha. Pugnou, ao final, pela procedência total do pedido inicial. Juntou documentos (f. 01-48).

Este Juízo proferiu decisão interlocutória de admissibilidade do feito. Ao ensejo, determinou a citação da parte requerida (f. 54-55).

Citada (f. 61), a parte demandada apresentou contestação. Na hipótese, não arguiu preliminares. No mérito, sustentou que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. Ainda, refutou a tese apresentada pela parte autora argumentando que não houve negligência por parte de preposto ou da instituição hospitalar. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos contidos na peça inaugural (f. 86-109).

A impugnação à contestação apresentada combateu a tese contestatória e finalizou reiterando os termos da petição inicial (f. 131-135).

O feito foi saneado. Na oportunidade, determinou-se a realização de prova pericial (f. 146-148).

Na sequência, a parte autora foi submetida a exame pericial, cujo laudo foi juntado às f. 165-181.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anastácio
1ª Vara

Ambas partes manifestaram acerca do laudo pericial (f. 184-186 e f. 188-190).

É o relato do essencial. **DECIDO.**

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por **Rosemeire Marina Neves Costa contra Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - Hospital Cassems - Unidade Aquidauana,** cuja pretensão é ser indeniza por abalo moral e dano estético sofrido.

II. 1 – DA (IN)APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Sabe-se que em se tratando de contrato de plano de saúde, as regras prevista do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis. Por outro lado, o Códex Consumerista não é aplicado em relação aos contratos administrados por entidades de autogestão Aliás, o e. STJ sedimentou o entendimento por meio da súmula n. 608, veja-se:

> Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Conforme o Estatuto da requerida CASSEMS, constata-se que a mesma atua na modalidade autogestão (f. 110-126), razão pela qual, inaplicável do CDC. Confira-se:

> "Art. 1º. A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul é pessoa jurídica de direito privado, associação civil de fins assistenciais não lucrativos, na modalidade de autogestão, constituída em Assembleia Geral de 16 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Antonio Maria Coelho, 6.065, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, passando a utilizar a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

abreviatura CASSEMS como sua marca."

Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em questão, incidindo as regras da legislação civil.

II. 2 – DO MÉRITO

No caso, a pretensão autoral está estampada em suposta negligência/imperícia dos prepostos da parte requerida, ao argumento de que a conduta dos respectivos teria resultado em dano estético, consequentemente, também dano moral.

Dessa forma, antes de mais nada, é necessário se apurar a responsabilidade civil da parte requerida acerca do evento danoso, a fim de que sejam apreciados os demais requerimentos da parte autora.

Pois bem. Nos termos do Código Civil, "o empregador responde por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele"[1].

Ainda, o enunciado n. 191 da III Jornada de Direito Civil assim estabelece:

> A instituição hospitalar privada responde, na forma do art. 932, III, do Código Civil, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, "não se pode negar a formação de um autêntico contrato entre o cliente e o médico, quando este o atende. Embora muito já se tenha discutido a esse respeito, hoje já não pairam mais dúvidas sobre a natureza contratual da responsabilidade médica. Pode-se falar, assim, em tese, em inexecução de uma obrigação, se o médico

[1] Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
(...)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anastácio
1ª Vara

não obtém a cura do doente, ou se os recursos empregados não satisfizerem. Entretanto, "**o fato de se considerar como contratual a responsabilidade médica não tem**, **ao contrário do que poderia parecer**, **o resultado de presumir a culpa**" (Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil – Vol. 04, São Paulo: Saraiva Educação, 2021).

Ainda, leciona que "que a responsabilidade contratual pode ou não ser presumida, conforme se tenha o devedor comprometido a um resultado determinado ou a simplesmente conduzir-se de certa forma. É o que sucede na responsabilidade do médico, que não se compromete a curar, mas a proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão".

Nesse raciocínio, a não obtenção da cura, a princípio, não importa reconhecer que o médico foi inadimplente, uma vez que a obrigação assumida pela respectivos profissionais é de "meio" e não de "resultado".

Portanto, a responsabilidade do médico atendente em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração da demonstração de qualquer das modalidades de culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Nesse passo, cabe diferencias as hipóteses de culpa. Assim, **imprudência** é a precipitação ou o ato de proceder sem cautela. **Negligência** é a inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, capacidade, solicitude e discernimento. E **imperícia** é falta de habilidade ou inaptidão para praticar certo ato.

Feito as devidas considerações, passa-se à análise do laudo pericial para verificação da incidência de uma das hipóteses da culpa. Vejamos as conclusões cruciais do *expert* (f. 165-181):

> **EM RELAÇÃO AO DANO ESTÉTICO NA ORELHO DIREITA:**
> ***"DANO ESTÉTICO CONSISTE EM QUALQUER TRANSFORMAÇÃO, OFENSA À HARMONIA FÍSICA DA PESSOA, COM UM DESEQUILÍBRIO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE, UMA MODIFICAÇÃO PARA PIOR, POIS CAUSOU DEFORMAÇÕES GRAVES, DEIXANDO A PESSOA COM APARÊNCIA DESFIGURADA DE FORMA PERMANENTE".***
> **NO PRESENTE CASO, HOUVERAM LESÕES RESIDUAIS E PERMANENTES QUE FORAM DIMINUÍDAS COM OS TRATAMENTOS INSTITUÍDOS.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anastácio
1ª Vara

7. Qual o prazo/tempo máximo para reconstrução primaria da orelha após a lesão? **Dependeria das condições que estavam as partes lesadas. A reconstituição desta unidade anatômica requer muito da imaginação do cirurgião, da sua experiência pessoal e conhecimento técnico. Fragmentos pequenos de orelha amputadas devem ser suturados se limpos e com tempo inferior a 6 horas.**
8. Seria possível afirmar/concluir que se a autora tivesse tido o devido encaminhamento ao hospital adequado pela forma mais rápida, teria menor extensão de danos em sua orelha? **Não, pois no caso em tela, a reconstrução foi feita com sucesso.**

6. O tempo decorrido entre o acidente, 16:00 horas, a liberação da vagas na Santa Casa de Campo Grande, 22:30 horas, associado ao tempo de viagem até a Santa Casa de Campo Grande, cerca de 2 horas e meia, totalizando cerca de 10 horas após o acidente, permitiria um reimplante de pavilhão auricular lesado em cerca de ¾? **Não.** Qual o tempo recomendado para se tentar a reconstrução primária, quando possível? **6 horas**

7. O fato da Autora necessitar de intubação orotraqueal, ainda em Aquidauana, fls. 3 e 43, "Como o quadro clínico da autora piorou repentinamente, sendo inclusive necessária à sua intubação endotraqueal" (fls 3) "Nesse ínterim, a paciente teve um agravo no quadro de saúde e necessitou ser entubada até aguardar a chegada da ambulância. O médico plantonista ficou a todo instante presente próximo da paciente, o que demonstra a gravidade do quadro de saúde dela naquele momento." (fls. 43) significa que o quadro era grave e instável? **Sim.**
8. Para realização de transporte rodoviário, por cerca de 2:30 horas, é necessário que o paciente esteja estabilizado, com via aérea garantida, enfim cumprindo todo protocolo médico ABCDE do ATLS? **Sim.**

3. Qual deve ser o prazo/tempo médio para transportar o paciente até outro hospital? **Não há um tempo padronizado, mas o fechamento primário pode ser feito de imediato (tempo menor do que 6 horas entre lesão e início de tratamento), ou retardado. Quando há contra-indicação para fechamento do ferimento, o tratamento é feito de forma aberta podendo ser fechado de forma secundária se evoluir bem.**

Pois bem. O laudo pericial elucida a questão e afasta qualquer das hipóteses de culpa. A inobservância de normas que nos ordenam agir com atenção, capacidade, solicitude e discernimento, não foi evidenciada.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anastácio
1ª Vara

Nota-se que a equipe médica prestou todo atendimento necessário à parte autora, que deu entrada no hospital às 17:40h (f. 31), e necessitou ser entubada em decorrência de agravamento do quadro clínico, inclusive, a autora ressalta que o médico plantonista permaneceu ao seu lado a todo instante (f. 03 e f. 43).

Vê-se, portante, que a equipe médica se apresentou diligente e atenta ao quadro clínico da parte autora.

Ademais, não há falar em imperícia, ao passo que o experto nomeado por este juízo foi claro ao estabelecer que a reconstrução da orelha foi feita com sucesso (f, 174). Além disso, asseverou que o tempo recomendado para se tentar uma reconstrução primária de orelha é de 6 (seis horas (f. 174), tempo que, se levando em conta o horário do acidente de trânsito e o horário da entubação da autora, não seria suficiente para tentativa de reconstrução.

Diante das provas produzidas, conclui-se que a reconstrução da orelha da parte autora foi feita com sucesso (f. 174), restando apenas dano em grau residual equivalente a 10%, não sendo evidenciado por parte da parte requerida e prepostos qualquer omissão, falta de cuidado e/ou ausência de qualificação pra desempenhar as funções incumbidas capazes de serem responsabilizados pelos danos alegados pela autora.

Em outras palavras, o requerente não se desincumbiu de seu ônus de prova estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa linha, "in verbis":

> EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ... MÉRITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PARTE RÉ – RECURSO IMPROVIDO... De acordo com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, **o ônus da prova incumbe**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Anastácio
1ª Vara

> **ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A não desincumbência desse ônus implica no julgamento da improcedência do pedido, mormente quando a parte ré demonstra de forma cabal a improcedência das alegações.** (TJMS. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível n. 0067118-34.2010.8.12.0001. Campo Grande. Desembargador Relator Claudionor Miguel Abss Duarte. Julgado em 19 de março de 2013). Grifei

No que concerne ao dano moral, por via de logicidade, é impossível apontar que a personalidade da parte requerente foi atingida.

Ora, não configurada a violação à dignidade da parte requerente, **posto que sequer ocorreu o consumo da bebida, eis que a parte autora aponta na petição inicial que "antes de abrir a garrafa constatou uma mosca",** não nasce o direito à indenização por dano moral.

Portanto, o pedido inicial não prospera.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido inicial.

Em consequência da sucumbência, **condeno** a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restara suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Anastácio-MS, *data da assinatura digital.*

Luciano Pedro Beladelli
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO PEDRO BELADELLI, liberado nos autos em 30/06/2021 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800017-70.2019.8.12.0052 e código qos43coz.